

1500657-31.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Santhyago eram as mesmas.

Enfim, pois, Santhyago deve igualmente ser condenado por tráfico.

Já no tocante ao crime de associação para o tráfico, no entanto, a absolvição é medida de justiça.

Como apontou o Ministério Público em alegações finais, "quanto ao crime de associação para o tráfico, verifico que não há elementos seguros para a sua comprovação, uma vez ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500657-31.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500657-31.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2161501/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 12219929 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9035/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2161501 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2161501 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 9035/20/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELDER RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

ELDER RODRIGUES DO NASCIMENTO, RAFAEL GUSTAVO DE AZEVEDO GALVÃO e SANTHYAGO CICERO DOS SANTOS PEREIRA foram dados como incurso nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11343/2006, porque: no dia 02 de julho de 2020, por volta de 21:30 h, na avenida das Bandeiras, Parque São João, nesta cidade, traziam consigo, visando entregar a consumo de terceiros, quatro porções de maconha com peso de 215,37

gramas, substância que determina dependência física e psíquica; na mesma data e horário, na rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira, n. 3-33, Bloco 18, apartamento 43, Água da Grama, nesta cidade, tinham em depósito, visando entregar a consumo de terceiros, uma porção de maconha com peso de 11,5 gramas, substância que determina dependência física e psíquica; na mesma data e horário, na rua Sargento José dos Santos, n. 2-70, Jardim Rosa Branca, tinham em depósito quatro porções de maconha com peso de 35,21 gramas, substância que determina dependência física e psíquica; e ainda, nos meses de junho e julho de 2020, nesta cidade, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Os réus Elder e Rafael foram notificados (fls. 306 - Elder; fls. 367 - Rafael).

Os acusados Elder e Santhyago apresentaram a defesa preliminar de fls. 316/325, aduzindo que: 1)- são usuários de maconha e compram droga juntos, para pagar mais barato e evitar comparecer constantemente na biqueira; 2)- Elder foi agredido pelos policiais com socos na face e cabeça, os quais ainda o obrigaram a fornecer a senha de seu celular e viram suas mensagens, notando que se encontraria com Santhyago; 3)- os policiais obrigaram o primeiro a enviar mensagens para o segundo, informando que passaria na sua casa, o que é corroborado pelo fato de Rafael lhes ter dito que saiu com Elder para fazerem uso de droga juntos, e pelo fato de Santhyago ter dito que sempre fazia uso de droga com Elder e que a armazenava em sua casa para consumo de ambos; 4)- foi comprovado que o dinheiro apreendido adveio do recebimento de auxílio devido ao "mesmo" em razão de patologia de seu filho; 5)- eram 14 notas de R\$ 50,00 e 4 notas de R\$ 20,00, ou seja, valores altos; 6)- não se caracterizou o crime de associação para o tráfico; 7)- a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; 8)- a apreensão recaiu sobre 250,58 gramas de maconha, quantidade de que os usuários se valiam para consumo em conjunto; 9)- deve ser reconhecido o tráfico privilegiado e a pena privativa de liberdade ser substituída por pena restritiva de direitos.

O réu Rafael apresentou a resposta à acusação de fls. 374/377.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 02 de julho de 2021 (fls. 382/384).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados (fls. 467 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a parcial procedência da ação penal, condenando-se os réus apenas pelo crime de tráfico (fls. 500/505).

Já a defesa técnica dos réus Elder e Santhyago se manifestou a fls. 511/521, reiterando a defesa preliminar e alegando, mais, que: 1)- não foram demonstrados o intuito de traficância e nem o ânimo associativo; 2)- os policiais disseram que os réus não são conhecidos dos meios criminosos; 3)- não foi encontrado indício de situação de mercancia e a quantidade de droga não descarta a posse para mero consumo; 4)- a prova confirma que os réus faziam uso de modo costumeiro e conjunto; 5)- não há prova do crime de associação; 6)- os acusados faziam uso conjunto de droga após o trabalho. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, a aplicação da pena mínima, a fixação do regime inicial aberto, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a aplicação do acordo de não persecução penal.

O acusado Rafael apresentou as alegações finais de fls. 525/547, aduzindo que: 1)- interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime; 2)- nada foi encontrado em poder do réu quando da abordagem, a não ser seu telefone celular; 3)- a droga foi encontrada em poder de Elder, sob o assoalho do carro de propriedade dele; 4)- na casa de Rafael, foram apreendidos cerca de 16 gramas de maconha em porção única, o que é compatível com a condição de usuário; 5)- por qual motivo, que não o abuso policial, Elder e Rafael iriam se prejudicar, confessando o crime e indicando a parceria de Santhyago; 6)- a versão dos réus, de que se conheciam do condomínio e usavam drogas juntos, bem como de que Elder e Rafael saíram naquela data para consumo conjunto de entorpecente, é verossímil, a par de confirmado pela testemunha Gisely; 7)- o crime de associação para o tráfico não se caracterizou; 8)- deve ser aplicado o privilégio de que trata o § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei n. 11343/2006, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão de fls. 29/30 (R\$ 740,00; uma balança com duas pilhas; uma faca; um rolo de plástico filme; dois telefones celulares; e substância análoga a maconha) e pelo laudo pericial de fls. 233/237 (duas porções de maconha com peso de 81,26 gramas – em posse de Elder; duas porções de maconha com peso de 134,11 gramas – no interior do veículo Gol, sob o assoalho do banco direito do passageiro; quatro porções de maconha com peso de 35,21 gramas – na residência de Santhyago; e uma porção de maconha com peso de 11,5 gramas – na residência de Rafael).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos aos réus.

Em juízo, a testemunha Otávio Avelino Licursi de Souza, policial militar, afirmou que, durante patrulhamento, deparou-se com um veículo Gol. O motorista de tal automóvel acelerou ao ver a polícia. No entanto, seus ocupantes, Elder e Rafael, foram abordados. Com Elder, que dirigia o carro, foram encontradas duas porções, dinheiro e um celular. Com Rafael, que estava no banco do passageiro, havia apenas um celular. Depois da busca pessoal, os dois foram indagados se havia algo mais de ilícito. Feita a revista no veículo, outras porções de droga foram achadas no assoalho do passageiro. O material estava, ali, visível. Os réus confirmaram a presença do material ilícito no veículo e indicaram Santhyago e o respectivo imóvel. Equipes da polícia foram até à casa dele. Santhyago autorizou o ingresso dos policiais. A namorada dele ali estava e acompanhou as buscas. Foram encontrados uma quantidade de droga, balança e plástico filme. Quando Elder e Rafael foram abordados, admitiram que o entorpecente presente no carro seria destinado ao tráfico. Eles se referiram a Santhyago como alguém que preparava a droga. Os dois não explicaram para onde estavam levando o entorpecente, apenas disseram que o pegaram com Santhyago. Os policiais, depois que saíram da casa de Santhyago, foram para a de Rafael. Este último houvera dito também que, na própria casa, havia droga. Ali diligenciando, a polícia encontrou mais entorpecente. Rafael morava no condomínio Água da Grama. Tratava-se de maconha. Na casa de Rafael, o entorpecente foi encontrado em um quarto. Não se recorda se o quarto era de Rafael. No imóvel, moravam ele e a mãe. Não se lembra se mais alguém morava na residência de Santhyago, nem mesmo a namorada. Santhyago disse somente que a droga encontrada em sua casa lhe pertencia, mas nada relatou sobre eventual vínculo com os demais. Não os conhecia até então. Havia quantidade de dinheiro na blusa de frio de um dos réus. Não se recorda do montante do numerário e nem como era composto. Não se recorda também se os réus disseram algo sobre o dinheiro. A droga estava embalada em porções pequenas. A balança de precisão e o plástico filme não estavam juntos com o entorpecente. Não se lembra onde tais itens estavam. Não sabe dizer como a droga estava na casa de Rafael, nem se era uma ou mais porções. Desconhece se havia comércio de entorpecente entre os acusados.

A testemunha José Carlos Cruz, também policial militar, relatou que, durante patrulhamento, passou por um veículo Gol. Seus dois ocupantes olharam para a viatura e aumentaram a velocidade. No entanto, eles foram perseguidos e abordados. No bolso de um deles, foram achados porções de entorpecente e dinheiro. Os dois indicaram que, no carro, havia mais droga, e informaram que outra pessoa picavam o entorpecente para que eles fizessem o comércio, indicando-lhe a casa. Os policiais foram até o imóvel em questão, onde localizaram mais droga, na presença da própria esposa do morador. Um dos ocupantes do veículo, que acredita ser Rafael, indagado, declarou que, em sua residência, também havia droga. Os policiais foram até a casa de Rafael e, autorizados pela mãe dele, entraram no imóvel e acharam entorpecente no quarto. Acredita que Rafael estava no banco do passageiro, pois o motorista era Elder. Segundo informado pelo soldado Licursi, a droga estava no assoalho do veículo, do lado de Rafael. Tratava-se de maconha. As porções estavam

acondicionadas para venda. "Tanto que batia com as embalagens encontradas na casa do outro rapaz", cuja esposa franqueou a entrada. Cuidava-se de mesmas embalagens. Não se recorda como eram as embalagens. A quantia em dinheiro consistia em R\$ 740,00, em várias cédulas, cujos valores não se recorda. Elder disse que o dinheiro era dele a acabou admitindo que provinha da venda de entorpecente. Santhyago admitiu a propriedade do material encontrado em sua casa, bem como que picava a droga para os demais comercializarem. Na casa de Rafael, a droga também consistia em maconha. Rafael residia num condomínio. A mãe dele disse não concordar com o que o filho estaria fazendo. O entorpecente foi achado no quarto de Rafael, pelo soldado Licursi. Não se lembra se havia mais alguém naquele imóvel. Na casa de Santhyago, estava presente a esposa dele, a qual acompanhou toda a vistoria. Não se lembra se mais alguém residia no imóvel de Santhyago. Elder e Rafael, quando abordados, informaram que Santhyago picava e embalava a droga, para que os dois pudessem levar até outro ponto de venda. Não os conhecia até então.

A testemunha Gisely Falcão de Lima disse ser esposa de Elder. Não são casados. Mantém relacionamento há dez anos. Elder é usuário de maconha. Moravam no mesmo bloco em que Rafael. Não conhece Santhyago e, portanto, não sabe falar sobre a amizade dele com seu esposo. Elder faz uso de maconha há cerca de oito anos. Quando iniciaram o relacionamento, sabia disso. Atualmente, tem mais conhecimento a esse respeito. Naquela data, Elder lhe falou que sairia com Rafael. Não o questionou na ocasião. O policial bateu em sua porta. Perguntou quem era. Foi falado que era a polícia. Achou que fosse uma brincadeira. Quando abriu a porta, os policiais já entraram e foram falando que Elder estava com eles. Os policiais estavam um pouco exaltados. Pediu-lhes que falassem baixo, pois tinha uma filha de dois anos e uma filha com autismo, que estavam dormindo. Os policiais indagaram se ela tinha conhecimento e pediram para olhar o armário. Os policiais abriram a porta do quarto das crianças. Eles não acharam nada. Os policiais lhe disseram que, se achassem algo em sua casa, ela iria "junto" e seus filhos iriam para o Conselho Tutelar. Em seguida, os policiais saíram de sua residência. Elder saiu do trabalho, passou em casa e saiu. Não se recorda quanto tempo se passou até que a polícia viesse em sua residência, acredita que tenha se passado mais de um hora. Elder não falou o que iria fazer. Ele costumava fazer "isso" com frequência. Como tem dois filhos, sabia que Elder saía para fumar droga.

Interrogado em juízo, Elder declarou terem sido abordados pela polícia, que encontrou uma porção de maconha. A droga seria destinada ao consumo. Faz uso de maconha desde 12 anos. Deixava-a no carro, para que não ficasse perto de seus filhos em casa. Rafael mora no mesmo condomínio. Usava drogas junto com Rafael e Santhyago. Quando abordados, foram coagidos. Os policiais queriam armas e mais alguma coisa. Foi então que os levou até a casa de Santhyago. Os policiais disseram que iriam prendê-lo, a não ser que os levassem até algum outro lugar. Sabia que havia droga na casa de Santhyago. Tinha uma empresa de compra e venda de embalagens. Tem dois filhos, uma menina de quatro anos e um menino de oito anos. Sua esposa trabalha num projeto social. Ela ganha cerca de mil reais. A renda mensal de sua empresa variava em torno de três mil reais. A maconha que estava no carro lhe pertencia. Rafael estava consigo porque saíram para fumar no carro. Sai de casa à noite para fazer uso de droga. Atualmente, tem consumido entorpecente na residência. Não deixava droga guardada no imóvel de Santhyago. Ele morou no mesmo condomínio anteriormente, e então o conheceu. Tinham amizade e consumiam maconha juntos. Os policiais o agrediram. Estava numa rua muito escura e ficou com medo de morrer. Eram vários policiais, altos e fortes. Como eles queriam mais coisas, levou-os até a casa de Santhyago. Explicou aos policiais que tinha aquela quantidade de droga porque não gostava de ir toda hora na biqueira. Era rotineiro um chamar o outro para se reunirem e fumarem. O dinheiro apreendido em sua posse adveio de pagamento de sua empresa. Fez compras e depósitos no mesmo dia.

Interrogado em juízo, o réu Rafael disse que estava de carona. Não falou nada na ocasião e não sabe de nada. Não tinha "consciência" de droga no carro, a não ser quando os policiais os abordaram. Havia acabado de enrolar um cigarro de maconha. Elder passou em sua casa e lhe chamou para ir a algum lugar com ele. Não havia lugar específico. Entrou no carro com seu cigarro. Sua intenção era apenas fumar e

voltar. Elder não disse o que iriam fazer em outro local. Não conhece Santhyago. Já saiu com Elder para fumar droga. Não usavam entorpecente no prédio, pois ali não podia. Não era sempre, mas, quando coincidia, iam usar drogas. Isso ocorria no período da noite, após o trabalho. Na data do fato, saíram para fumar maconha. Trabalha como marceneiro. Havia tomado banho e descido, quando então encontrou-se com Elder. Em sua casa, havia somente dez gramas de maconha, numa única porção, que estava enrolada num envelope. Já havia aberto o envelope e pegado um pouco do material. Em sua casa, não havia balança ou "essas coisas". Apenas seu celular foi apreendido.

Interrogado em juízo, o acusado Santhyago declarou disse ter conhecido os corréus no condomínio Água da Grama. Ali morava com sua mãe. Sempre se encontravam para fumar no condomínio ou fora dele. Compravam porções maiores para não terem que ir sempre na biqueira. Deixava guardada em sua casa alguma quantidade. Às vezes, Elder ali passava para que saíssem a fim de fumar. Trabalha como auxiliar de pintor. Na época dos fatos, auferia até dois mil e quinhentos reais por mês. Em sua residência, havia duas ou três porções pequenas de maconha. Morava com sua esposa. Ela estava em casa quando a polícia esteve no imóvel. Não guardava droga para Elder. Sua esposa está passando por uma dieta em razão da gravidez e, por isso, usava a balança. Quando da abordagem, ficou muito assustado. Não guardava droga para Elder. O que havia em sua residência, pertencia-lhe. A irmã de sua esposa entrega salgadinhos. Ela pediu que pegasse o insufilm, que estava fechado na data do fato. Iria entregar o insufilm para sua cunhada. No momento da abordagem, disseram-se para falar que a droga era de Elder. Como sua esposa estava grávida, ficou com medo de perder o parto de seu filho. Seu depoimento na delegacia baseou-se naquilo que foi ordenado pelos policiais. Eles chegaram no portão de sua casa e não perguntaram se estava fumando. Apenas começaram a afirmar que havia maconha dentro da residência. Permitiu que eles entrassem no imóvel. Quando localizaram a droga, os policiais não lhe perguntaram se o material lhe pertencia e se o usava. Eles lhe disseram que era traficante e fazia a distribuição de maconha. Os policiais também afirmaram que, se não falasse que o entorpecente era de Elder, seria colocado como traficante e preso.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em suas defesas que sustentam o contrário.

Isto porque, segundo depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, no assoalho do banco do passageiro do veículo dirigido por Elder, então ocupado por Rafael, foram encontradas nada menos do que duas porções de maconha com peso de 134,11 gramas (conforme laudo pericial).

Outrossim, na posse de Elder, havia outras duas porções de maconha com peso de 81,26 gramas.

Assente-se inexistir razão para não se atribuir peso probatório às declarações dos policiais, na medida em que eles não teriam motivos para conduzir os réus até a delegacia e depois vir em juízo, a fim de afirmar, perante o magistrado e as partes, fatos inverídicos em detrimento de pessoas que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e criminalmente pela falsa acusação.

Como quer que seja, nenhum elemento de convicção relevante, a desdizer o que fora afirmado pelos agentes públicos, foi produzido, anotado que o depoimento da testemunha Gisely, por ser esposa de Elder, é evidentemente suspeito.

Prosseguindo, não é possível conceber que todo aquele material apreendido se destinava a consumo.

O argumento de que se adquiria droga em maior quantidade para evitar ter que se dirigir à "biqueira" por várias vezes é pueril.

Afinal, todos sabem que é muito menos arriscado portar menor quantidade de entorpecente do que aquela que os réus traziam consigo.

Dito de outro modo, compensava, e muito, perder tempo de ter que se dirigir ao ponto de tráfico por mais de uma vez, a fim de comprar quantidades menores.

É que, em caso de eventual flagrante pela posse de pequena quantidade de droga, a imputação certamente se referiria ao artigo 28 da Lei Antidrogas, e não ao artigo

33, cuja pena é bem maior.

Ademais, a alegação de que os réus consumiam drogas juntos, embora possa ser verdadeira, não elide o crime de tráfico no caso concreto.

Veja-se que, somado o montante de entorpecente que estava em poder direto de Elder (81,26 gramas) com aquele que estava no assoalho do banco do passageiro (134,11 gramas), atinge-se o resultado de 215,37 gramas.

Seria bem mais pueril ainda acreditar que duas pessoas fossem, sozinhas, fazer uso de tamanha quantidade de entorpecente numa só ocasião.

A fala de Elder, no sentido de que deixava a droga no carro, ao invés de no interior de sua casa, a fim de não ser percebida pelos filhos, é igualmente inverossímil.

Afinal, se os filhos poderiam encontrar o entorpecente dentro da residência, poderiam também achá-lo no interior do automóvel, o qual, certamente, ficava estacionado no imóvel da família.

Não bastasse, os filhos tinham quatro e oito anos, ou seja, eram crianças de tenra idade.

É impossível acreditar que, numa residência, não exista local para guarda de material inapropriado não somente para todos, mas sobretudo para menores, situado em altura incompatível com o alcance por parte de crianças.

Não vinga, da mesma forma, o argumento de que os réus Elder e Rafael somente assumiram a prática do tráfico e indicaram a comparsaria de Santhyago em razão de coação exercida pelos policiais.

Não é incomum que agentes flagrados em plena prática criminosa assumam, perante os responsáveis pelas suas prisões e no calor do momento, o ilícito cometido.

Estão os primeiros, afinal, em situação de vulnerabilidade e sujeição em relação aos segundos, de quem, naquele momento específico do flagrante, não têm mais o que esconder, haja vista que o contexto de fato da abordagem fala por si só.

Sob a mesma ótica, justifica-se a delação feita em relação a Santhyago, tanto mais se se considerar que Elder e Rafael foram levados a colaborar com o trabalho da polícia não por terem sido coagidos, mas justamente em razão daquela posição de sujeição e, mais, pela busca de conseguir que suas situações restassem assim de alguma forma amenizadas.

Especificamente quanto ao réu Rafael, não é possível alegar que ele não sabia da existência da droga no veículo.

Observe-se que, segundo o policial Otávio Avelino Licursi de Souza, o material ilícito estava "visível" dentro do automóvel.

E não se perca de vista, no aspecto considerado, que Rafael estava sentado justamente no banco em cujo assoalho o entorpecente estava.

De resto, cabe ponderar que as confissões e a delação, embora informais, não devem ser desprezadas no conjunto probatório, pois amparadas pelo fato de que, na residência do terceiro indicado pelos réus confidentes e delatores, a polícia encontrou não apenas droga, como também balança, faca e um rolo de plástico filme, "no rack da sala da residência de Santhyago" (fls. 29).

A jurisprudência já assentou o entendimento, baseado no princípio do livre convencimento motivo do magistrado, que, quando corroborada por outros indícios, a confissão informal e, por extensão, a delação informal, são elementos de prova que não podem ser desconsiderados na formação da convicção judicial.

Nesse sentido:

"A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: 'O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram' (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal - 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da

confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual - Tráfico ilícito de entorpecentes - Prova - Depoimentos de policiais - Indícios e circunstâncias que convencem da autoria - Condenação mantida (...). Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. em 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

Enfim, pois, a outra conclusão não se pode chegar senão à de que os réus Elder e Rafael estavam cometendo tráfico, não sendo viável cogitar de absolvição e nem mesmo de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11343/2006.

Quanto a Santhyago, a mesma solução se impõe.

Insista-se que, na casa dele, a apreensão recaiu sobre quatro porções de maconha com peso de 35,21 gramas (conforme laudo pericial), bem como balança, faca e um rolo de plástico filme, localizados "no rack da sala da residência" (fls. 29)

Diante disso, não é possível sustentar que o réu é inocente ou mero usuário.

Se a balança servisse para fins culinários ou de dieta, certamente não estaria na sala, e sim na cozinha, cômodo este apropriado para a guarda de alimentos.

Se o plástico filme seria entregue por Santhyago para sua cunhada, que trabalhava com salgadinhos, seria fácil demonstrar o alegado.

Ocorre que a defesa não comprovou nem que a cunhada laborava com a confecção e venda de salgados e nem que solicitou a Santhyago a entrega do plástico filme.

A inércia, no ponto em questão, é sintomática.

De resto, é fora de dúvida a coautoria no tráfico entre Elder e Rafael, de um lado, e Santhyago, de outro.

A par do que já se sustentou, inclusive quanto à seriedade da delação informal no caso concreto, não se deve olvidar a afirmação do policial José Carlos Cruz, a dar conta de que as embalagens das porções de maconha encontradas no veículo e na casa de Santhyago eram as mesmas.

Enfim, pois, Santhyago deve igualmente ser condenado por tráfico.

Já no tocante ao crime de associação para o tráfico, no entanto, a absolvição é medida de justiça.

Como apontou o Ministério Público em alegações finais, "quanto ao crime de associação para o tráfico, verifico que não há elementos seguros para a sua comprovação, uma vez que o tipo penal exige o dolo de se associar com estabilidade e permanência (animus associativo), configurando-se, na hipótese, concurso de agentes meramente ocasional". (fls. 505).

Logo, os acusados devem ser absolvidos da imputação referente ao artigo 35 da Lei Antidrogas.

Passa-se à aplicação das penas.

Os réus não tem antecedentes criminais (Elder - fls. 59, 80 e 275/277; Rafael - fls. 60 e 77/78; e Santhyago - fls. 61, 75 e 281/283).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Os acusados fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11343/2006.

É certo que a apreensão recaiu sobre quantidade relativamente elevada de entorpecente.

Apenas a partir desse dado, no entanto, não se pode extrair a ilação de que se está diante de agentes que se dedicam a atividade criminosa, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

O fato de também terem sido apreendidos balança, plástico filme e faca, no caso concreto, é igualmente insuficiente para arredar o privilégio.

Afinal, a apreensão recaiu sobre uma só balança e um só rolo de plástico filme, o que não confere certeza quanto à traficância em larga escala e sim, ao revés, de modo artesanal e limitado.

De resto, inexistem outros elementos de convicção a partir dos quais se possa formar convencimento de que os réus integram organização criminosa ou de que se dedicam a atividade criminosa.

No aspecto considerado, aliás, diga-se que o próprio representante do Ministério Público pediu, em alegações finais, a absolvição no tocante ao crime de associação para o tráfico.

Cabível o privilégio, a redução da pena, porém, não pode se dar no patamar máximo de dois terços.

Isto porque a quantidade de maconha destinada ao tráfico foi de 250,58 gramas (sem considerar a quantia de 11,5 gramas encontrada na casa de Rafael, esta sim possível objeto de futuro e mero consumo).

Cuidando-se de quantidade razoável, a redução da pena deve se dar no patamar de um terço, resultando em três anos e quatro meses de reclusão, mais trezentos e trinta e três dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.

Como visto, não há prova de que os réus eram dedicados a atividade criminosa ou integravam organização criminosa, e tinham em seu poder, no total, quantidade de entorpecente que, se relativamente elevada, não o era a tal ponto de ensejar risco de especial prejuízo aos usuários e à sociedade, se se considerar tratar-se de maconha.

Não se está, aqui, querendo dizer que a maconha é droga cuja natureza é inofensiva e que seu comércio e consumo deveriam ser liberados.

O que se está sustentando, simplesmente, é que o entorpecente em questão é menos prejudicial à saúde humana e à sociedade como um todo se comparado a outros.

Não por outro motivo, em ação em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, já há votos de Ministros sustentando a descriminalização do porte de maconha.

Levando em conta, mais, que os réus não têm antecedentes criminais, cabível o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Considerando as mesmas circunstâncias, entendem-se presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar os réus Elder Rodrigues do Nascimento, Rafael Gustavo de Azevedo Galvão e Santhyago Cicero dos Santos Pereira como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4o, da Lei n. 11343/2006, a cumprirem três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagarem trezentos e trinta e três dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, a ser definida em execução, bem como para absolvê-los da acusação de cometimento do crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, anatem-se as condenações no sistema informatizado.

Quanto aos telefones celulares, balança, faca e plástico filme apreendidos, trata-se de bens cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou destruídos, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

P.R.I.

Bauru, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA